

刑法  
No93

H19-2

(配点：3)

|   |   |
|---|---|
| 月 | 日 |
| 月 | 日 |

次の【事例】について、甲及び丙の行為がいずれも傷害罪の構成要件に該当するとした上で、後記の【見解】ⅠないしⅣを採って検討した場合、後記1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

## 【事例】

甲は、自分に向けてけん銃を構えた乙から、「そこで腕を縛られて座っている丙の右腕をバットで殴って骨折させろ。そうでないとお前を射殺する。」と告げられたので、やむを得ず乙の指示に従って丙の右腕を目掛けてバットを振り下ろしたところ、丙は、殴打されるのを避けるためにやむを得ず、バットを持った甲の右腕を蹴り上げた。甲は、丙に蹴られたため右腕を骨折し、丙は、甲が振り下ろしたバットが軽く接触したにとどまったため、右腕に軽い打撲傷を負ったものの、骨折は免れた。

## 【見解】

- Ⅰ. 刑法第37条第1項は、違法性阻却事由を定めたものである。ただし、形式的に同条同項の要件を充たす場合でも、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っているようなときは、同条同項の適用は認められない。
  - Ⅱ. 刑法第37条第1項は、違法性阻却事由を定めたものである。犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っていたとしても、同条同項の要件を充たす場合には、同条同項の適用は認められる。
  - Ⅲ. 刑法第37条第1項は、原則として違法性阻却事由を定めたものであるが、被侵害法益と保全法益とが同価値である場合は責任阻却事由を定めたものである。ただし、形式的に同条同項の要件を充たす場合でも、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っているようなときは、同条同項の適用を認めるべきではない。
  - Ⅳ. 刑法第37条第1項は、原則として違法性阻却事由を定めたものであるが、被侵害法益と保全法益とが同価値である場合は責任阻却事由を定めたものである。犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っていたとしても、同条同項の要件を充たす場合には、同条同項の適用を認めてよい。
1. Ⅰの立場によれば、甲の行為も丙の行為も違法性が阻却される。
  2. Ⅱの立場によれば、甲の行為も丙の行為も違法性が阻却される。
  3. Ⅲの立場によれば、甲の行為も丙の行為も責任が阻却され得るにとどまる。
  4. Ⅳの立場によれば、甲の行為も丙の行為も違法性が阻却される。
  5. Ⅳの立場によれば、甲の行為も丙の行為も責任が阻却され得るにとどまる。

No93

## 強要による緊急避難

正答率

H19-2

正解

2

77%

本事例において、甲は、自分に向けてけん銃を構えた乙から、「そこで腕を縛られて座っている丙の右腕をバットで殴って骨折させろ。そうでないとお前を射殺する。」と告げられたので、やむを得ず乙の指示にしたがって丙の右腕を目掛けてバットを振り下ろしている。本事例の被侵害法益は丙の身体であるのに対し、保全法益は甲の生命であり、法益の権衡が認められる。このような本件事情から、本事例の甲の行為は形式的に緊急避難（37条1項）の要件を充たす。ただし、甲は乙に利用されており、不法を行う側に立っている。

また、丙は、殴打されるのを避けるためにやむを得ず、バットを持った甲の右腕を蹴り上げ、その結果甲は右腕を骨折している。本事例の被侵害法益は甲の身体（右腕）であるのに対し、保全法益は丙の身体（右腕）であり、法益の権衡が認められる。このような事情から丙の行為は、甲のバットを振り下ろすという行為の違法性が阻却されない場合は正当防衛（36条1項）の要件を充たし、甲の行為の違法性が阻却される場合は緊急避難の要件を充たす。正当防衛の正当化根拠については、違法性阻却にあると解されている。

一般に緊急避難の不処罰根拠については、緊急避難を（A）違法性阻却事由と位置付ける説、（B）責任阻却事由と位置付ける説、（C）二分説がある。そして（C）二分説は、（イ）法益同等の場合をそれ以外と区別して責任阻却事由とするものと、（ロ）生命・身体に対する避難の場合を区別して責任阻却事由とするものに分かれる。

本問では、これらのうち、（A）違法性阻却事由と位置付ける説（見解Ⅰ、Ⅱ）と（C）二分説の（イ）法益同等の場合をそれ以外と区別して責任阻却事由とする説（見解Ⅲ、Ⅳ）を基本にしつつ、本事例における甲のように、形式的に緊急避難の要件を充たす場合であっても、犯罪者に利用されるなど行為者が不法を行う側に立っているような場合に、37条1項の適用があるかについて対立する見解が挙げられている。

## 1 誤っている

Ⅰは、形式的に37条1項の要件を充たす場合でも、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っているようなときは、同条同項の適用は認められないとする見解である。甲は犯罪者乙に利用されており、Ⅰの立場によれば、同条同項の適用は認められないため、甲の行為は違法性が阻却されない。したがって、本記述は誤っている。なお、甲の行為の違法性が阻却されないことから、丙の行為は正当防衛となり、違法性が阻却されるから、本記述の丙の行為に関する部分は正しい。

## 2 正しい

Ⅱは、37条1項の要件を充たす場合には、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っていたとしても、同条同項の適用は認められ、違法性が阻却されるとする見解である。甲は犯罪者に利用されているが、Ⅱの立場によれば、甲に同条同項の適用は認められるため、違法性が阻却される。また、甲の行為の違法性が阻却されることから、これに対する丙の行為は緊急避難となり、違法性が阻却される。したがって、本記述は正しい。

### 3 誤っている

Ⅲは、形式的に37条1項の要件を充たす場合でも、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っているようなときは、同条同項の適用を認めるべきではないとする見解である。甲は犯罪者乙に利用されており、Ⅲの立場によれば、同条同項の適用を認めるべきではないため、甲の行為は違法性及び責任が阻却されない。したがって、本記述は誤っている。なお、甲の行為の違法性が阻却されないことから、丙の行為は正当防衛となり、違法性が阻却される。したがって、本記述は丙の行為に関する部分についても誤っている。

### 4 誤っている

Ⅳは、37条1項の要件を充たす場合には、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っていたとしても、同条同項の適用を認めてよいとする見解である。甲は犯罪者に利用されているが、Ⅳの立場によれば、甲に同条同項の適用が認められる。そして、被侵害法益と保全法益とが同価値ではない（身体対生命）ため、Ⅳの立場からは甲の行為は違法性が阻却されることとなる。したがって、本記述の甲の行為に関する部分は正しい。もっとも、丙の行為については、被侵害法益と保全法益が同価値（身体対身体）なため、責任が阻却され得るにとどまる。したがって、丙の行為も違法性が阻却されるとする点で、本記述は誤っている。

### 5 誤っている

Ⅳは、37条1項の要件を充たす場合には、犯罪者に利用されるなど、行為者が不法を行う側に立っていたとしても、同条同項の適用を認めてよいとする見解である。甲は犯罪者に利用されているが、Ⅳの立場によれば、甲に同条同項の適用が認められる。もっとも、甲については、被侵害法益と保全法益とが同価値ではない（身体対生命）ため、Ⅳの立場からは甲の行為は違法性が阻却されることとなり、責任が阻却されるわけではない。したがって、甲の行為は責任が阻却され得るにとどまるとしている点で、本記述は誤っている。なお、丙の行為については、被侵害法益と保全法益がともに右腕の骨折であり同価値（身体対身体）なため、責任を阻却され得るにとどまるから、本記述の丙の行為に関する部分は正しい。